

1502115-25.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... que não possui envolvimento com o tráfico, embora seja usuário de maconha e cocaína. Os policiais os abordaram e revistaram a residência de seus avós, lá encontrando a sacola contendo as drogas, mas negou que fossem suas. Disse que já foi preso em 2018, por tráfico, mas "pagou" e, como menor, teve uma passagem. Ao final, disse que não conhecia os policiais que realizaram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502115-25.2022.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502115-25.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203951/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 26393043 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2203951 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON HENRIQUE FRANCO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

ANDERSON HENRIQUE FRANCO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 40, inciso VI, da referida Lei de Drogas, tudo c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, em 27 de julho de 2022, à tarde, na rua Austrália, altura do nº 13, Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Salto/SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustado e com unidade de desígnios com os adolescentes M. O. S. e L. L., guardava, trazia consigo e tinha em depósito, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, 70 (setenta) porções de "cocaína", com peso bruto de 58,8g (cinquenta e oito gramas e oitenta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi oferecida em 17 de agosto de 2022 (fls. 63/67), o réu foi notificado

(fls. 99) e apresentou defesa prévia (fls. 103/107). A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2022 (fls. 110/112) e o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas 02 testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 143/146).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da agravante constante da denúncia e da reincidência, além da causa de aumento consistente na participação de adolescente, entendendo não ser possível a benesse do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, requereu a imposição de regime inicial fechado, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 149/154). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação a pena-base no mínimo legal, a desconsideração das agravantes relativas à reincidência e ao cometimento de crime durante o estado de calamidade pública, além do afastamento da causa de aumento de pena constante da denúncia. Ao final, requereu a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 156/163).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/05), autos de exibição, apreensão e constatação preliminar (fls. 08/09), laudo químico-toxicológico (fls. 74), além da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório. O réu, em sede policial, negou que estivesse traficando. Disse que estava na companhia dos adolescentes M. O. S. e L. L., e que a droga era de L., mas não sabe se os menores possuem envolvimento com o tráfico (fls. 14/15). Em juízo, disse que não são verdadeiros os fatos. Contou que morava no Jardim Marília, com sua mãe e irmãos, trabalhava como ajudante de pintor, com seu tio, e ia à casa de seus avós quase que diariamente, pois ajudava a avó a cuidar do avô, que sofre de Alzheimer. Contou que estava na frente da casa de seus avós, acompanhado dos adolescentes M. O. S. e L. L., mas disse que não possui envolvimento com o tráfico, embora seja usuário de maconha e cocaína. Os policiais os abordaram e revistaram a residência de seus avós, lá encontrando a sacola contendo as drogas, mas negou que fossem suas. Disse que já foi preso em 2018, por tráfico, mas "pagou" e, como menor, teve uma passagem. Ao final, disse que não conhecia os policiais que realizaram a abordagem (fls. 146).

Mário Bruno de Souza, policial militar, disse que, no dia dos fatos, estavam patrulhando em Rocam, em 2 motos, passaram pelo bairro e pela rua Austrália, conhecido ponto de tráfico, onde avistaram 04 rapazes na esquina, tendo um deles recebido algo do réu, e se evadido. O adolescente M. gritou e alertou sobre as viaturas e o réu arremessou uma sacola para dentro da casa da esquina. Com o réu, foram apreendidos R\$131,00 (cento e trinta e um reais) e um celular; com o menor L., mais R\$120,00 (cento e vinte reais) e com o Matheus, nada se achou. A residência para onde viram o réu arremessar a sacola era da avó de Anderson, e lá localizaram a sacola arremessada, contendo 70 porções de cocaína. O menor L. confessou a prática do tráfico de drogas e disse que havia em sua casa, um simulacro de arma de fogo, que foi também apreendido. O local onde eles foram abordados fica bem próximo de escola e área de lazer. O Anderson, vulgo "Zóio", já tinha sido visto outras vezes no mesmo ponto em que foi abordado, e já havia várias denúncias sobre a presença do réu nos bairros Santo Inácio, Jardim Marília (região dos predinhos) e sobre seu envolvimento no tráfico desses locais. O réu negou todos os fatos, enquanto L. assumiu que estaria traficando sozinho e não apontou nenhum outro integrante (fls. 145).

Sylvio Tronchini Stein, policial militar, prestou depoimento consonante com o de seu colega de farda, acrescentando que L., ao assumir que estaria traficando sozinho, disse que Anderson seria seu patrão. Ao final, afirmou que não havia aglomeração de pessoas no local (fls. 145).

Inicialmente, cumpre consignar que as responsabilidades dos adolescentes já foram apuradas nos autos de nº 1502116-10.2022.8.26.0526, onde lhes foram aplicadas as medidas socioeducativas pertinentes.

No presente feito, após encerrada a instrução, verifica-se que a negativa do réu se mostrou isolada do restante do conjunto probatório.

Os policiais militares foram claros ao alegarem que viram 04 pessoas na esquina, e presenciaram quando o réu entregou algo a uma dessas pessoas, que fugiu ao perceber a chegada da polícia. Logo em seguida, viram o adolescente M. avisando aos demais que permaneceram ali, quais sejam, o réu Anderson e o também adolescente L., sobre a chegada da polícia, e viram também, que este último arremessou uma sacola para dentro do imóvel.

Durante a abordagem, não encontraram droga com os adolescentes ou o réu, mas ao encontrarem a sacola, que viram ser jogada para dentro do imóvel (que depois se veio a saber ser a residência dos avós do réu), constataram que ela estava cheia de porções de cocaína.

Ora, a dinâmica narrada ficou perfeitamente clara: os adolescentes e o réu praticavam estavam juntos, no local, para realizarem a traficância. Malgrado o trio tenha negado, os policiais flagraram a entrega de parte da droga a uma pessoa não identificada, que acabou fugindo, além de terem visto quando se livraram das drogas, jogando a sacola que as continha para dentro do imóvel.

Nesse trilhar, os depoimentos dos mencionados agente policiais, seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depoís negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistiu qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado ou os menores, até porque os menores, no feito de apuração de Ato Infracional, assim como o réu, no presente feito, manifestaram que não conheciam os policiais.

Tal fato demonstra que inexistia qualquer problema anterior entre os policiais que realizaram a abordagem, as apreensões e a prisão, com relação aos abordados. Como já mencionado no feito de apuração de ato infracional, é pouco crível que os agentes policiais andem com tamanha quantidade de entorpecentes na moto, com o propósito exclusivo de poderem prejudicar pessoas, por envolvimento anterior por tráfico de entorpecentes, quando sequer conhecem os potenciais indiciados. Endossar tal tese seria subverter e inverter por demais, a ordem das coisas, em teorias mirabolantes e sem substrato.

Por fim, não é demais recordar que o próprio réu confirmou ter tido passagens anteriores por tráfico, uma enquanto menor e outra após atingir a maioridade.

Portanto, restou plenamente provada a ocorrência da traficância por parte do réu, assim como o envolvimento dos adolescentes, de modo que se encontra inconteste a incidência da causa de aumento prevista no 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, o pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 27 de julho de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que o réu praticou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 40, inciso VI, da referida Lei de Drogas, tudo c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j"

(calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, em 27 de julho de 2022, à tarde, na rua Austrália, altura do nº 13, Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Salto/SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustado e com unidade de desígnios com os adolescentes M. O. S. e L. L., guardava, trazia consigo e tinha em depósito, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, 70 (setenta) porções de "cocaína", com peso bruto de 58,8g (cinquenta e oito gramas e oitenta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restaram provadas, de forma inconteste, a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta do acusado, razão pela qual, passo a lhe aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, e tendo em vista que a quantidade e a natureza da droga apreendida

não destoam daquilo que comumente se observa em apreensões análogas realizadas na comarca, fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, qual seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o delito de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

Como acima mencionado, incide a agravante atinente à prática de crime durante o estado de calamidade pública. Ademais, Anderson é reincidente, porquanto possui condenação definitiva, também por tráfico de drogas, nos autos de nº 0000027-95.2018.8.26.0569 (fls. 35), sendo certo não haver decorrido o prazo depurador de cinco anos entre o cumprimento da pena e o cometimento do crime pelo qual é julgado nestes autos, mais uma vez por tráfico.

Ante a presença das agravantes do artigo 61, incisos I e II, alínea "j", aumento a pena do acusado para 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Mostra-se presente, também, a causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da lei em comento, já que o crime envolveu 02 adolescente, razão pela qual aumento a pena 2/6, resultando em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

O envolvimento do réu com o tráfico possui constância suficiente para demonstrar que faz do crime seu meio de vida, seja porque não comprovou qualquer atividade lícita, e essa incumbência era da Defesa, seja porque já foi processado por tráfico enquanto menor e, posteriormente, condenado no processo crime de nº 0000027-95.2018.8.26.0569 (fls. 35) e, voltando a ser preso por tráfico alguns meses após o cumprimento da pena.

Assim, não é possível a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO o réu ANDERSON HENRIQUE FRANCO, qualificado nos autos, RG 63.165.616, como incurso no artigo artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 40, inciso VI, da referida Lei de Drogas, tudo c.c. artigo 61, incisos I e II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 anos de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 800 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade do delito praticado (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas sobretudo pelo potencial lesivo de sua conduta e da abrangência da venda de drogas que vinha realizando, inclusive com o envolvimento de menores, atingindo a centenas de usuários caso não houvesse sido preso, bem como por suas conduta desregrada, dedicação ao crime e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado. Pelas mesmas razões, adicionando-se a dedicação ao crime, não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Acrescente-se a isso que o réu é reincidente (ostenta condenação anterior com trânsito em julgado por violação de direito autoral (fls. 176/177), a evidenciar que faz do crime meio de vida e que a condenação anterior não foi suficiente para reeducá-lo, tanto que persiste na empreita delitiva, a justificar o tratamento mais severo. Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido" (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO

DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução.

Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).

Assim, o réu deverá aguardar no cárcere o julgamento definitivo do feito, porquanto permanecem presentes os motivos que ensejaram, inicialmente, sua custódia cautelar. Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Decreto o perdimento de todos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios da Procuradora nomeada, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá à advogada interessada providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA